

1500594-03.2022.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... de fachada que, na verdade, era ponto de tráfico de entorpecentes), e os péssimos antecedentes criminais, circunstâncias concretas obstativas da aplicação da referida minorante. 8. Ordem denegada." (STF HC 111.666/MG Rel. Min. Luiz Fux j. 08.05.12 DJU 23.05.12).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

2ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500594-03.2022.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500594-03.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY RUPI BUENO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

WESLEY RUPI BUENO foi denunciado por incursão no caput do art. 33 da Lei no 11.343/06.

Narra a denúncia que, no dia 25 de março de 2022, por volta das 16h30min, na Rua Manoel Nascimento, 1, Jardim Zaira, nesta cidade de Mauá, o acusado expunha à venda, para fins de tráfico, drogas ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 09-10 e laudo de constatação de fls. 13-5.

Recebida a denúncia, o réu foi citado (fl. 123) e apresentou resposta à acusação.

Testemunhas arroladas pelas partes devidamente inquiridas. Por fim, o réu foi interrogado.

Em memoriais finais, o Ministério Público requer a procedência da ação penal, enquanto a Defesa suscita a nulidade da instrução por ofensa ao § 14 do art. 28-A do Código de Processo Penal. No mérito, busca a absolvição por insuficiência de provas, ou, ao menos, a fixação da pena no patamar mínimo, reconhecendo-se o tráfico privilegiado, sob regime penitenciário inicial aberto, além da substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos.

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

De partida, não há nulidade a ser reconhecida.

Malgrado o esforço argumentativo do douto Defensor Público, a questão atinente ao acordo de não persecução penal já foi devidamente afastada no momento oportuno, destacando-se a falta de requisito objetivo (fls. 104-9).

No mérito, procede a acusação.

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 05-7), auto de exibição e apreensão (fls. 09-10), laudo de constatação (fls. 13-5), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 114-6), além da prova oral colhida.

Comprovou-se a autoria.

Interrogado, em solo policial, o réu permaneceu em silêncio (fl. 04). Sob o contraditório, alegou que estava em via pública, com um grupo de pessoas, quando gritaram dizendo que a polícia havia invadido o local. As pessoas assustaram-se e começaram a correr, motivo pelo qual também correu e acabou sendo detido pelos policiais. Negou estar com a bolsa e o local não era ponto de tráfico. Disse que não conhecia os policiais que realizaram a abordagem (mídia digital).

A versão do acusado está isolada do conjunto probatório e não merece credibilidade.

O policial militar Diego, na fase administrativa, historiou que (sic) "estava participando de operação denominada "ABC Seguro", e juntamente com seu parceiro Sgt PM Bressan, realizavam patrulhamento com motocicletas, visando coibir o tráfico de entorpecentes. Que ao chegar ao local dos fatos, uma viela, local já conhecido como ponto de venda de drogas avistaram um indivíduo com uma bolsa marrom nas mãos, em atitude suspeita de tráfico, e companhia de um segundo indivíduo o qual conseguiu se evadir. O indivíduo que estava com a bolsa nas mãos, mais tarde identificado como sendo o indiciado Wesley Rupi Bueno, ao perceber a presença das motocicletas da Polícia Militar, tentou correr, porém foi logo alcançado e detido. Na bolsa que o indiciado carregava estavam diversas substâncias aparentando serem entorpecentes, crack, maconha e cocaína. Na revista pessoal foi encontrada a quantia de R\$ 10,00 (dez reais), mais nada foi encontrado. Apesar das buscas o segundo indivíduo não foi localizado. No local, o indiciado, informalmente admitiu estar praticando o tráfico no local" (fl. 02).

No mesmo sentido as declarações do policial militar Evandro (fl. 03).

Em juízo, os policiais militares reiteraram integralmente suas declarações. Confirmaram estar participando de uma operação destinada a coibir o tráfico de drogas, oportunidade em que visualizaram o réu, em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, correndo com uma bolsa nas mãos. Abordado, o réu admitiu a narcotraficância. O policial militar Diego acrescentou que viu outro indivíduo

correndo, porém ele conseguiu fugir. Disse, também, que havia outros moradores no local, mas somente o réu e o outro suspeito correram. O policial militar Evandro, por sua vez, afirmou que estava atrás de Diego e não viu o segundo indivíduo. Na mesma linha que seu colega de farda, relatou que as demais pessoas que estavam na comunidade não correram (mídia digital).

A prova por meio de depoimento de policiais não é desvaliosa, quanto ao actum a que corresponda, pela só condição profissional das testemunhas. Ao revés, estar-se-ia diante de uma acepção processual de pessoas com apoio em predicado genérico. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que não é causa simpliciter de menor credibilidade a circunstância de uma testemunha ser policial. Nessa linha:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07).

Observe-se que o depoimento prestado em juízo pelos policiais, além de plenamente coerentes, estão em perfeita harmonia àqueles por eles prestados perante a Autoridade Policial. Não há nos autos prova alguma, sequer indícios, de que os policiais tivessem motivo particular, injusto, para incriminar falsamente o réu.

No mais, descabida a alegação da Defesa quanto à ilegalidade na busca pessoal, uma vez que os policiais que realizaram a abordagem afirmaram que, em local conhecido pela prática de tráfico de drogas, visualizaram o réu correndo com uma bolsa nas mãos, de forma que demonstradas as fundadas razões para a busca pessoal.

No mais, a quantidade de droga encontrada e as demais circunstâncias da apreensão, tais como a variedade e a forma em que era transportada, o local da abordagem, ponto de tráfico, além do dinheiro apreendido, trazem elementos suficientes de que o réu tinha a droga para entrega a terceiros.

Dessa forma, entendo que o delito de tráfico de drogas está fartamente comprovado.

Passo à fixação da pena.

Atendendo aos ditames do art. 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base do acusado 1/6 acima do mínimo legal, em razão da grande quantidade de drogas apreendida - 83 porções de cocaína (65,2 gramas), 132 porções de maconha (444,1 gramas) e 127 porções de crack (22,3 gramas) - fator que justifica a majoração da reprimenda penal, na medida em que incrementa o potencial ofensivo à saúde pública (bem jurídico tutelado pela norma penal), revelando uma maior reprovabilidade da conduta dos agentes (STF, HC 73.097, rel. Min. Maurício Corrêa, HC nº 76.543-5, rel. Min. Sydney Sanches; STJ, HC nº 35.539, rel. Min. Paulo Medina, HC nº 35.795, rel. Min. Nilson Naves, HC nº 35.159, rel. Min. Hamilton Carvalhido), perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Sobre o potencial lesivo da quantidade de cocaína e "crack" apreendida:

"A cocaína pode produzir uma intoxicação grave e por vezes inesperadamente com pequenas doses. A dose letal pode estar entre 0,8 a 1,2 g para um homem de 70 kg. No entanto, fumadores de base livre reportam uso de quantidades que excedem a 1 g. Em contrapartida, há casos em que se pode ocorrer o óbito com uma dose extremamente

baixa de 20 mg. Isto pode ser explicado pela ocorrência da tolerância reversa que se caracteriza ou pelo aumento da susceptibilidade ao aparecimento de convulsões em doses consideradas recreacionais ou por uma excitação aumentada obtida em doses menores em usuários crônicos, fato que pode ser explicado pela diminuição da biossíntese dos neurotransmissores, o que leva a uma potencialização dos efeitos excitatórios." (Passagli, Marcos; Toxicologia Forense – Teoria e Prática, 5ª ed., Millennium: Campinas, 2018 – pg. 180-1).

Na fase intermediária, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Não deve incidir, no caso concreto, a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Não se desconhece que a quantidade do entorpecente, nos termos da Repercussão Geral no ARE nº 666.334/AM, rel. Min. Gilmar Mendes, deve ser ponderada em apenas uma das fases da dosimetria da pena, sob pena de bis in idem.

Todavia, diante das demais circunstâncias do delito - réu trazia consigo considerável quantidade e variedade de entorpecentes, em local conhecido como ponto de tráfico, notoriamente dominado por facções criminosas, portanto sem espaço para "iniciantes", além de não ter comprovado de forma mínima o exercício de atividade lícita - parece-me claro o acentuado envolvimento do acusado no comércio de drogas, ou seja, a não ocasionalidade da conduta.

Repita-se que, nesta etapa, não há bis in idem na valoração da quantidade de drogas, já que tal circunstância foi utilizada apenas supletivamente, conjugada com outros vetores do caso concreto, para o afastamento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Nessa linha, posiciona-se o e Superior Tribunal de Justiça:

"Não há bis in idem quando o Tribunal a quo fixa a pena-base acima do mínimo em razão da quantidade e natureza da droga apreendida e afasta o redutor do art. 33 § 4º da Lei n. 11.343/2006 em razão da dedicação do paciente à atividade criminosa, que restou evidenciada pela quantidade e nocividade da droga apreendida (um quilo de maconha). Também não há bis in idem quando a quantidade e a natureza da droga são consideradas na primeira fase da dosimetria da pena e, logo depois, no momento da fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda" (STJ, AgRg no REsp 1690827 MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).

Ainda sobre o redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, I, DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. AFASTAMENTO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. ANÁLISE DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA OU DE SER INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADES NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM DENEGADA. 1. A causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da lei 11.343/06 está condicionada ao preenchimento, cumulativo, dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. [...] 3. A conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza do entorpecente, os apetrechos utilizados e as circunstâncias em que a droga foi apreendida podem constituir o amparo probatório para o magistrado reconhecer a dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes: RHC 94.806/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/04/2010; HC 116.541/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/6/2013; HC 98.366/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira

Turma, DJe de 5/2/2010. [...] (STF HC 121.057/SP Rel. Min. Luiz Fux j. 25.02.14 DJU 18.03.14).

"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA, MAUS ANTECEDENTES E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PRESUNÇÃO HOMINIS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS. APTIDÃO PARA LASTREAR DECRETO CONDENATÓRIO. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REAPRECIÇÃO DE PROVAS. DESCABIMENTO NA VIA ELEITA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A AFASTAR A MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06, ANTE A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ORDEM DENEGADA. 1. O §4º do artigo 33 da Lei de Entorpecentes dispõe a respeito da causa de diminuição da pena nas frações de 1/6 a 2/3 e arrola os requisitos necessários para tanto: primariedade, bons antecedentes, não dedicação à atividades criminosas e não à organização criminosa. 2. Consectariamente, ainda que se tratasse de presunção de que o paciente é dedicado à atividade criminosa, esse elemento probatório seria passível de ser utilizado mercê de, como visto, haver elementos fáticos conducentes a conclusão de que o paciente era dado à atividade delituosa. 3. O princípio processual penal do favor rei não ilide a possibilidade de utilização de presunções 'hominis' ou 'facti', pelo juiz, para decidir sobre a procedência do 'ius puniendi', máxime porque o Código de Processo Penal prevê expressamente a prova indiciária, definindo-a no art. 239 como 'a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias'. Doutrina (LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. v. II. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. p. 161-162). Precedente (HC 96062, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-02 PP-00336). 4. Deveras, o julgador pode, mediante um fato devidamente provado que não constitui elemento do tipo penal, utilizando raciocínio engendrado com supedâneo nas suas experiências empíricas, concluir pela ocorrência de circunstância relevante para a qualificação penal da conduta. 5. A criminalidade dedicada ao tráfico de drogas organiza-se em sistema altamente complexo, motivo pelo qual a exigência de prova direta da dedicação a esse tipo de atividade, além de violar o sistema do livre convencimento motivado previsto no art. 155 do CPP e no art. 93, IX, da Carta Magna, praticamente impossibilita a efetividade da repressão a essa espécie delitiva. 6. O juízo de origem procedeu a atividade intelectual irrepreensível, porquanto a apreensão de grande quantidade de droga é fato que permite concluir, mediante raciocínio dedutivo, pela dedicação do agente a atividades delitivas, sendo certo que, além disso, outras circunstâncias motivaram o afastamento da minorante. 7. In casu, o Juízo de origem ponderou a quantidade e a variedade das drogas apreendidas (1,82g de cocaína pura, 8,35g de crack e 20,18g de maconha), destacando a forma como estavam acondicionadas, o local em que o paciente foi preso em flagrante (bar de fachada que, na verdade, era ponto de tráfico de entorpecentes), e os péssimos antecedentes criminais, circunstâncias concretas obstativas da aplicação da referida minorante. 8. Ordem denegada." (STF HC 111.666/MG Rel. Min. Luiz Fux j. 08.05.12 DJU 23.05.12).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA: INADMISSIBILIDADE. DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO VOLTADA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA: CIRCUNSTÂNCIAS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06 E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA: IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. [...] 6. Os fatos que deram ensejo à não aplicação da causa de diminuição de pena prevista na Lei de Tóxicos são hígidos e suficientes para atestar a dedicação do Paciente às atividades criminosas. 7. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas. [...] (STF HC 109.236/SP Rel.

Min. Cármen Lúcia j. 13.12.11 DJU 14.23.12).

Define-se, assim, a condenação em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

O valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica do acusado.

Registre-se que o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 44 da Lei 11.343/06, nas partes em que se vedava a concessão de liberdade provisória (HC n. 104.339, rel. Min. Gilmar Mendes) e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (HC n. 97,256, rel. Min. Ayres Britto), bem como do parágrafo 1º do art. 2º da Lei n. 8072/90, que impunha o regime inicial fechado (HC n 111.849, rel. Min. Dias Toffoli).

Todavia, a gravidade in concreto do delito, considerando o alto potencial lesivo da cocaína e do crack para saúde pública, indica um grau acentuado de culpabilidade, de forma que o regime inicial fechado mostra-se necessário para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE COMO FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL E PARA A NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ORDEM DENEGADA. Possibilidade de fixar regime inicial fechado e de afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. Precedentes.Ordem denegada.” (STF – HC 119.515/AC – Rel. Min. Cármen Lúcia – j. 03.12. – DJU 10.12.13)

Pelo mesmo motivo, não é hipótese de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, insuficiente para prevenção e reprovação da conduta.

Posto isso, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu WESLEY RUPI BUENO, qualificado nos autos, a cumprir pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e a pagar 583 dias-multa, no patamar mínimo, por incursão no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Faculta-se ao réu o apelo em liberdade.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e oficie-se para a destruição da contraprova das drogas e do estojo apreendido (fls. 09-10). Além disso, decreto a perda dos valores (fls. 73-6), em favor do Funad, eis que comprovadamente obtidos com a narcotraficância, nos termos dos arts. 63 e 72 da Lei n.º 11.343/2006.

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella – Juiz de Direito
(assinado eletronicamente)

Mauá, 04 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA